

1500470-39.2020.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO SANTOS VILELA

Comarca: Cachoeira Paulista

Foro: Foro de Cachoeira Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO O MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA A CONDENAÇÃO DO RÉU TAMBÉM POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, QUE SEJA AFASTADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, CASSADA A SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS E FIXADO O REGIME FECHADO RAZÃO EMPARTE CONDENAÇÃO BEM LANÇADA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU QUANDO, NA COMPANHIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cachoeira Paulista

Foro de Cachoeira Paulista

1ª Vara

Praça Prefeito Prado Filho, s/nº, Cachoeira Paulista-SP - cep 12630-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500470-39.2020.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500470-39.2020.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2151861/2020 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA, 12033823 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA, 362/20/210 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA, 2151861 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE DOUGLAS FERNANDES SALOMAO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO SANTOS VILELA

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 129, I, da Constituição Federal c/c art. 41 do Código de Processo Penal, inicialmente em face de Carlos Augusto Moreira da Silva e de José Douglas Fernandes Salomão - qualificados e representados nos autos -, imputando-lhes prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em sua denúncia de fls. 1-6, o Parquet narrou:

[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 23 de junho de 2020, por

volta das 09 horas, na Rua José Gonçalves Diniz, nº. 355, bairro Vila Carmem, nesta cidade e comarca de Cachoeira Paulista, CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA, qualificado a fls. 06/07 e JOSÉ DOUGLAS FERNANDES SALOMÃO, qualificado a fls. 08/09, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de substâncias entorpecentes.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA, qualificado a fls. 06/07 e JOSÉ DOUGLAS FERNANDES SALOMÃO, qualificado a fls. 08/09, agindo em concurso de agentes pela unidade de designios visando o fim comum, guardavam e tinham em depósito, para fins de comércio a terceiros, Cocaína, consistente em 164,27g (cento e sessenta e quatro gramas e vinte e sete centigramas), distribuídas em 338 (trezentos e trinta e oito) pinos epperdofs, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes de fls. 45/47 e laudo de exame químico-toxicológico que será oportunamente juntado aos autos.

Segundo o apurado, policiais militares receberam informações no sentido de que o endereço acima informado era utilizado para embalar e armazenar substância entorpecente.

Assim, de posse das informações, os agentes públicos se deslocaram até o local e lá chegando, inicialmente, mantiveram contato com a testemunha Amanda, moradora da casa dos fundos que franqueou a entrada dos agentes.

Ao seguirem pelo corredor, avistaram o denunciado Carlos Augusto, o qual informou que estava residindo no local e franqueou a entrada dos policiais no imóvel, certo que no local também se encontrava o denunciado José Douglas, sendo que este indagado informou o local em que estaria escondida a droga.

No local indicado pelo denunciado José Douglas, os policiais arrecadaram a droga acima descrita, 04 potes de fermento químico com substância branca semelhante a cocaína, R\$50,00 (cinquenta reais) em dinheiro e 02 (dois) aparelhos de telefonia celular, sendo oportuno ressaltar que o denunciado José Douglas indicou que possivelmente haveria droga armazenada em outro endereço. Contudo, em busca realizada no local por ele indicado nada de ilícito foi encontrado.

As circunstâncias das diligências realizadas pelos policiais, o recebimento de denúncia indicando o local como ponto de embalo e armazenamento de droga, a quantidade de entorpecentes apreendidos e sua forma de seu acondicionamento, a apreensão de dinheiro, indicam, de forma segura, que os entorpecentes apreendidos destinar-se-iam ao comércio ilícito.

Assevere-se, ainda, que os denunciados estavam associados para a prática reiterada do crime de tráfico de entorpecentes.[...]

Recebida a denúncia às fls.179-181.

A denúncia foi aditada para inclusão de Jefferson Tomaz da Silva no polo passivo (fls.185-189). O aditamento foi recebido às fls. 389-391 e 406.

Decretada a prisão preventiva de Jefferson Tomaz da Silva às fls.197-200.

Impetrado habeas corpus, foi concedida a ordem em favor do réu Carlos Augusto (fl. 227).

Às fls.272-273, Carlos Augusto Moreira da Silva apresentou defesa prévia.

À fl.357, Jefferson Tomaz da Silva apresentou defesa prévia.

Às fls.399-402, José Douglas Fernandes Salomão apresentou defesa prévia.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária (art. 397 do Código de Processo Penal), designou-se audiência de instrução e julgamento (fls.389-391).

Durante a instrução (fl.456) foram colhidos os depoimentos de 04 testemunhas, e foi realizado o interrogatório dos réus.

As prisões preventivas de Jefferson Tomaz e de José Douglas foram revogadas às fls. 571-572.

O Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela parcial procedência da denúncia (fls.606-613).

José Douglas Fernandes Salomão juntou seus memoriais às fls.618-622 e pugnou pela absolvição.

Jefferson Tomaz da Silva, em suas alegações finais, às fls.626-632, requereu sua

absolvição, alegando insuficiência probatória.

Carlos Augusto Moreira da Silva, às fls.633-638, sustentou pela absolvição do réu; ainda, pela aplicação no mínimo legal, bem como a aplicação da benesse prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

1. Da imputação relativa ao tráfico de drogas

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 07/08), pelo boletim de ocorrência nº 362/2020 (fls. 16/19), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 20/21, 22/23, 24/26 e 26/27), pelo laudo de constatação provisória (fls. 51/53), pelo relatório complementar (fls. 145/149), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 246/248).

A autoria está parcialmente comprovada nos autos.

Leandro da Silva Ribeiro, policial militar, disse que receberam várias informações e denúncias de que no local ocorria o tráfico de entorpecentes. A denúncia dava conta de que Jefferson e Douglas estariam utilizando a residência para o tráfico de entorpecentes. No local, localizaram Amanda, que se identificou como moradora de uma das casas existentes no terreno. Amanda franqueou a entrada. No corredor visualizaram Carlos, que se encontrava dentro da segunda residência. Carlos também autorizou o ingresso dos policiais. Dentro da edificação, também se depararam com Douglas. Em conversa informal, este informou que o entorpecente estava armazenado no guarda-roupa. No local indicado, foram localizados 338 pinos contendo cocaína e quatro potes com substância branca. Ainda na residência foram localizados dois aparelhos celulares e R\$50,00 (cinquenta reais). Carlos disse que não sabia da existência das drogas. As denúncias envolviam apenas Jefferson e Douglas. Carlos não estava no quarto onde foi encontrada a droga. As denúncias envolvendo Jefferson e Carlos datavam de seis meses antes da abordagem. Os potes cheios de pó royal estavam no guarda-roupa, mas também foram localizados potes vazios na cozinha. Não foram realizadas diligências para prisão de Jefferson, porque ele estava viajando. Waldir Bittencourt Junior, policial militar, apresentou versão praticamente idêntica a de Leandro da Silva.

Juliana Coutinho Souza disse que alugou a casa para Jefferson e sua esposa, Cintia. Quem pagava o aluguel era Cintia. Não sabe onde Jefferson trabalhava. Desde março de 2020 não reside mais nas proximidades do local. Jefferson tem uma filha, mas não sabe se ela namora Carlos. Conhece a mãe de Douglas e por isso o conhece também. Moravam na casa Jefferson, Cintia e os filhos dela.

Amanda Fernandes Salomão declarou que não sabia que Douglas estava na casa de Jefferson. Eles se conhecem da rua, são amigos. Douglas morava em Lorena e trabalhava como servente. Aos finais de semana ele visitava a mãe em Cachoeira Paulista. Ele foi preso por tráfico de drogas em Lorena. Vitória é filha de Jefferson e namorada de Carlos. Carlos ficava na casa de Jefferson. Sempre o via por lá, morava no “Barranco”, mas não saía da casa de Jefferson. Nunca viu movimentação no local. Jefferson foi viajar por volta do dia 6 a 7 de junho. Enquanto Jefferson viajava, Carlos permaneceu no imóvel.

Carlos Augusto Moreira, em interrogatório, declarou que na data do ocorrido foi olhar a residência de Jefferson. Recorda-se de que no dia 10 de junho foi abordado naquele local por outros policiais. Dia 12, No dia 22, tinha um campeonato de videogame, então, foi para a casa de Jefferson, porque lá tinha melhores condições de jogar. Por volta das 21h00, José Douglas pediu pouso, e lhe deu autorização. No dia 23, às 08h00, foi abordado e autorizou a entrada dos policiais no local.

Acompanhou a busca na residência e presenciou a localização das drogas no armário de Jefferson. Ficou surpreso. Ficava na residência apenas para jogar. Dormiu no quarto de sua namorada e José Douglas dormiu no quarto de Jefferson ou na sala.

José Douglas estava apenas com a roupa do corpo. Não sabe dizer se ele saiu da casa durante a noite. Não tinha intimidade com José Douglas, então não sabe dizer se ele usava drogas. Nunca presenciou seu sogro usando drogas.

José Douglas Fernandes Salomão declarou que na data dos fatos saiu de Lorena às 19h00 para ir até a casa de sua mãe. Chegou em Cachoeira Paulista por volta das 21h00 e sua mãe estava dormindo. Encontrou Carlos, que estava indo jogar bola, então, o acompanhou. Após, foi convidado por Carlos para dormir no local. Aceitou. De manhã foi surpreendido pelos policiais, enquanto estava dormindo na sala. Os policiais perguntaram quem tinha passagem e, ao dizer que tinha, foi agredido e ameaçado por eles. Não teve contato com Carlos. O médico não constatou a agressão. Não foi dormir na casa da irmã porque estava tarde. Foi só com a roupa do corpo, porque tem roupa na casa de sua mãe. Foi Carlos quem autorizou sua estadia no local. Dormiu na sala, num colchão arrumado por Carlos. Não era comum frequentar o imóvel de Jefferson.

Jefferson Tomaz da Silva declarou que estava em sua casa quando a Força Tática foi até a sua residência. Autorizou o ingresso na sua casa e nada foi localizado. Eles pediram R\$20.000,00 (vinte mil reais) para não ser preso. Então, foi embora da cidade no dia seguinte e deixou Carlos em sua casa.

O mosaico probatório revelou que, a partir de denúncias anônimas indicando a comercialização de drogas na residência de Jefferson Tomaz da Silva, agentes de segurança pública começaram a realizar diligências no local. Segundo esclarecido pelo policial Leandro, pelo menos seis meses antes da apreensão do entorpecente, já se tinha conhecimento da prática dos delitos.

Além disso, segundo se extrai dos autos, alguns dias antes da prisão em flagrante, policiais foram até a casa do réu Jefferson, vasculharam a residência, mas nada encontraram.

Na data de 23/06/2020, os policiais fizeram nova investida no local. Após o ingresso autorizado, encontraram 338 pinos de cocaína no armário situado no quarto de Jefferson.

Não há dúvida de que Jefferson residia no local, ainda que estivesse temporariamente fora de casa por conta de uma viagem. Foram encontrados 338 pinos de cocaína dentro do seu armário, o que confirma, em parte, a denúncia anônima recebida pela polícia e, conseqüentemente, o seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Por outro lado, no momento da apreensão do entorpecente, estavam, na casa de Jefferson, Carlos Augusto Moreira da Silva e de José Douglas Fernandes Salomão, com os quais nada de ilícito foi encontrado.

Os policiais também não presenciaram nenhum ato de traficância por parte de José Douglas e de Carlos Augusto. O único indício apresentado no curso da instrução foi a denúncia anônima.

Não se produziu nenhum tipo de investigação com vistas a confirmar o envolvimento de José Douglas e Carlos Augusto com o tráfico de drogas. Eles não foram filmados ou fotografados vendendo drogas (não há notícia de campanas), tampouco se ouviu pessoa que pudesse dizer que comprou ou viu alguém adquirindo drogas dos réus enquanto estavam na casa de Jefferson.

Em razão da fragilidade do acervo probatório, o Parquet, em suas alegações finais, opinou pela absolvição de Carlos Augusto. Com razão o Ministério Público.

Ocorre que, no tocante ao réu José Douglas, de rigor também a sua absolvição. Isso porque, o acusado não mora no local. Segundo dito pelas testemunhas, ele apenas passou a noite na casa de Jefferson. De acordo com os policiais, José Douglas não portava nada de ilícito. As drogas foram encontradas no armário, onde ficam os pertences pessoais de Jefferson.

Sem que haja a presença de robusto acervo probatório não se pode responsabilizar criminalmente José Douglas por objetos encontrados dentro de armário de terceiros. Não se nega, por óbvio, a possibilidade do envolvimento de José Douglas com o tráfico de entorpecentes. Todavia, o decreto condenatório exige um juízo de certeza. Os elementos de prova, porém, não permitem tal conclusão.

O art. 5º, LIV, da Constituição Federal assegura a todo cidadão que ninguém será privado da sua liberdade sem o devido processo legal. Mais adiante, o inciso LVII estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Da mesma forma dispõe o art. 8º, 2, do Pacto de San José, incorporado pelo Decreto 678/92, que toda pessoa acusada de delito tem

direito a que se presume sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa.

A partir desses dispositivos, não resta dúvida de que o exercício da jurisdição penal deve observar o devido processo legal substantivo. Cabe ao Poder Judiciário, após presidir a instrução do feito, colher as provas necessárias para fundamentar a privação da liberdade do réu. Tal atividade probante, cujo resultado poderá infirmar a presunção de inocência do sujeito, deverá ser feita perante um Poder imparcial e equidistante, constitucionalmente destinado a preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Como se sabe, segundo a vertente probatória do princípio da presunção de inocência, incumbe ao Ministério Público demonstrar, além de dúvida razoável, que o acusado cometeu a infração penal descrita na denúncia.

Acerca da adequada interpretação do art. 156 do Código de Processo Penal e do princípio do in dubio pro reo, trago à baila as lições do Professor Afrânio Silva Jardim:

[...] somente a acusação é que alega fatos, atribuindo-os ao réu. Eventual 'alegação' deste, será tão-somente aparente, vez que juridicamente deve ser reputada como mera negação dos fatos alegados na denúncia ou queixa", isso porque, no processo penal, o réu é presumidamente inocente e a dúvida sempre o favorece. Sob tal prisma, não é aplicável de forma automática, no processo penal, a distribuição do ônus da prova regulada no processo civil, de forma a transferir ao acusado o dever de demonstrar sua inocência. Urge que a regra do art. 156 do CPP seja compreendida como "a faculdade que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. (JARDIM, Afrânio Silva. Direito Processual Penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 294-312).

Sendo assim, como o órgão de persecução penal, mesmo após a instrução processual, não logrou êxito em convencer o juízo de que os réus Carlos Augusto e José Douglas praticaram fato típico, ilícito e culpável, não há outra solução senão a absolvição dos acusados.

No tocante à tipicidade, concluo que o acusado Jefferson Tomaz da Silva, vulgo "Jefinho", com consciência e vontade, nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia, armazenava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 164,27g (cento e sessenta e quatro gramas e vinte e sete centígramas), distribuídas em 338 (trezentos e trinta e oito) pinos eppendorfs, razão pela qual praticaram a conduta típica prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Assim, à luz da teoria da indiciabilidade, praticada a conduta típica, presume-se também antijurídico o comportamento dos acusados, salvo se afastada a ilicitude pela prova produzida nos autos. No caso em apreço, não restou afastada a ilicitude por qualquer excludente.

A culpabilidade, com pressuposto de aplicação da pena, é indiscutível, vez que eram os acusados imputáveis no momento da ação, gozando de plena capacidade para entender o caráter ilícito dos seus atos, sendo-lhe exigível conduta diversa da adotada. Ou seja, inexistem dirimentes que amparem os acusados.

Da análise da certidão de antecedentes criminais de fls. 485-488, noto que Jefferson Tomaz foi definitivamente condenado nos autos de nº 0005618-66.2003.8.26.0180. como não transcorreu o período depurador de 5 anos entre a extinção da pena e os fatos que ensejaram a presente ação penal, reconheço a reincidência do acusado.

Saliento que, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em bis in idem pela majoração da pena em razão da reincidência e, conseqüentemente, pelo afastamento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que a incidência deste dispositivo tem como pressuposto a primariedade do agente.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. POSSE NO MOMENTO DO FLAGRANTE. REINCIDÊNCIA. MINORANTE

NEGADA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.
 2. Afasta-se a alegação de flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de drogas, que é de ação múltipla, consumando-se já pela conduta de guardar e manter em depósito a substância entorpecente.
 3. A utilização da agravante da reincidência para majorar a pena e afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, não caracteriza bis in idem.
 4. Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, impõe-se a manutenção do regime fechado, a teor do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do CP.
 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.
- (AgRg no AREsp 1637754/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020)

Por fim, esclareço que, como forma de evitar bis in idem e de observar a posição do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a variedade do entorpecente apreendido serão valoradas apenas na primeira fase.

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE E CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. MATERIAIS APREENDIDOS. IDENTIDADE DE FUNDAMENTOS NAS DUAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. AGRAVOS IMPROVIDOS.

1. Constitui indevido bis in idem a valoração negativa de idênticos fundamentos na primeira etapa da dosimetria da pena, para elevar a pena-base, e na terceira, para negar ou mesmo modular a fração da minorante do tráfico privilegiado.
 2. Agravos regimentais improvidos.
- (AgRg no REsp 1782263/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019)

2. Da imputação relativa à associação para fim de traficar drogas

Da análise dos autos, não se obteve nenhum elemento de informação acerca de um ajuste prévio, estável e permanente entre os réus para tal fim, não sendo indicadas relações anteriores que pudessem levar a crer que os acusados estão constantemente envolvidos com o tráfico de drogas.

A única informação extraída dos autos é que Carlos é ex genro de Jefferson, e estava em sua residência no dia da abordagem; ademais, que este conhecia José Douglas, o qual pediu para dormir em sua residência no dia em questão.

Para ser considerado o crime imputado aos réus:

“(…) exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os ajustes se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol. 1. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 417).

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPÇÃO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE NÃO DECLINARAM OBJETIVA E CONCRETAMENTE A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO AGENTE PARA A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DURADOURO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NÃO INDICADO. ÔNUS QUE SE IMPÕE NO SISTEMA ACUSATÓRIO. CONFIGURAÇÃO DE MERA REUNIÃO OCASIONAL. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DE RIGOR, NO PONTO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. PROVIMENTO ESTENDIDO AO CORRÉU. 1. Hipótese na qual o Tribunal de origem consignou que, em 26/07/2018, os dois Corréus guardavam e mantinham em depósito drogas e uma arma de fogo e munições de uso

permitido, e que, em dias anteriores, próximos a 25/07/2018, associaram-se para praticar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 2. Não foram apontadas concretamente circunstâncias que demonstrassem o intento dos agentes de se associarem de forma perene. As instâncias ordinárias, após examinarem o acervo probatório, não descreveram o animus associativo entre os Agentes. Ao ressaltar que o período da associação limitou-se aos dias anteriores próximos a 25/07/2018, e ao dia seguinte (26/07/2018), o Tribunal local não declinou fundamento válido para a conclusão de que houve vínculo duradouro entre os dois Corréus. Precedentes. 3. No mais, no ponto, ocorreu indevido reforço de fundamentação em recurso exclusivo da Defesa. 4. Constata-se tão somente a configuração do delito de tráfico de drogas em concurso eventual de agentes. Por isso, mostra-se indevida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, no qual o sistema acusatório impõe o ônus da "demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa" (HC 462.888/RJ, Rel. Ministro ROGERIOSCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe05/11/2018). 5. Não se descarta que, se tivessem as instâncias ordinárias declinado dos elementos concretos que demonstrassem que os Agentes, de forma estável e permanente, associaram-se para praticar o delito do art. 35 da Lei de Drogas, reexaminar a conclusão sobre a comprovação ou não do elemento subjetivo do tipo de associação para o tráfico implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório. Todavia, concluir que as instâncias ordinárias não se valeram do melhor direito para condenar o Agravante não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, no caso, não estão consignados os elementos subjetivos do tipo. 6. Recurso provido para absolver o Agravante da condenação por associação para o tráfico de drogas. Provimento estendido, em iguais termos, ao Corréu WILLIAM RIBEIRO DOS SANTOS, com fundamento no art. 580, do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 624.284/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021)

No mesmo sentido vem se posicionando o Tribunal de Justiça de São Paulo: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO O MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA A CONDENAÇÃO DO RÉU TAMBÉM POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, QUE SEJA AFASTADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, CASSADA A SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS E FIXADO O REGIME FECHADO RAZÃO EMPARTE CONDENAÇÃO BEM LANÇADA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU QUANDO, NA COMPANHIA DE ADOLESCENTES, "EMBALAVAM" PORÇÕES DE MACONHA NEGATIVA ISOLADA E RECHACADA PELOS RELATOS SEGUROS DOS MILICIANOS QUE EFETUARA A PRISÃO FRÁGEIS AS PROVAS QUANTO À PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO POSSIBILIDADE DE CONCURSO EVENTUAL, MERA COAUTORIA ABSOLVIÇÃO QUANTO A ESTE CRIME MANTIDA QUANTO À PENA IMPOSTA, COM RAZÃO O PLEITO MINISTERIAL APENAMENTO BENEVOLENTE A MINORANTE PREVISTA NOS 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006, É DESTINADA APENAS AO PEQUENO TRAFICANTE, POR ISSO DEVE SER AFASTADA DE RIGOR O REGIME FECHADO DIANTE DA QUANTIDADE DE PENA E CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DE EMPREITADA CRIMINOSA (ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES) PARCIAL PROVIMENTO PARA AUMENTAR PENA E FIXAR REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO ESGOTADAS AS IMPUGNAÇÕES ORDINÁRIAS NESTA CORTE DE JUSTIÇA. (TJSP; Apelação Criminal 0000470-18.2015.8.26.0580; Relator(a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 11/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018)

O acolhimento parcial da pretensão autoral, pois, é medida de rigor.

III – DOSIMETRIA

À luz do princípio da individualização da sanção penal (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal) e do critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Com relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei 11.343/06, entendo que a culpabilidade encontra-se dentro da normalidade do tipo; o réu possui maus antecedentes, os quais serão valorados na segunda fase; não há provas – laudo elaborado por psicólogo ou por assistente social – capazes de desabonar a personalidade e a conduta social do acusado; os motivos, as

consequências e as circunstâncias do crime não destoam do esperado; não há falar em comportamento da vítima na espécie; a natureza da droga mostrou-se desfavorável, tendo em vista que foi apreendido cocaína, entorpecente com enorme potencial para gerar dependência e prejudicar a saúde dos usuários; a quantidade de entorpecente embora significativa não se mostra exorbitante para fins de elevação da pena base. Sendo assim, elevo a pena em 1/8 e fixo a pena-base em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 563 dias-multa.

Reconheço a presença da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) e agravo a pena em $\frac{1}{6}$, de modo a fixá-la em 06 anos, 03 meses e 28 dias de reclusão e 633 dias multa.

Sem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Sendo assim, a pena definitiva do acusado é de 06 anos, 03 meses e 28 dias de reclusão e 633 dias multa.

Em relação ao regime de cumprimento de pena, considerando o quantum de pena aplicado, as circunstâncias judiciais e a reincidência, determino o cumprimento inicial em regime fechado, por força do disposto no art. 33, §2º, "a", e §3º, do Código Penal.

Ausentes elementos acerca da capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal.

Inviável tanto a substituição por restritiva de direitos quanto a aplicação da suspensão condicional da pena (arts. 44 e 77 do Código Penal).

IV - DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para:

(a) CONDENAR o réu Jefferson Tomaz da Silva como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e aplicar-lhe a pena privativa de liberdade de 06 anos, 03 meses e 28 dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 633 dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

(b) ABSOLVER Carlos Augusto Moreira da Silva Moreira da Silva e José Douglas Fernandes Salomão da imputação relativa à prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

(c) ABSOLVER os réus Carlos Augusto Moreira da Silva, José Douglas Fernandes Salomão e Jefferson Tomaz da Silva da imputação relativa à prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

V - DISPOSIÇÕES FINAIS

Sem detração e progressão de regime. Anoto que o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal não revogou o art. 66, III, "b", da Lei 7.210/84. A progressão de regime envolve a análise de elementos objetivos e subjetivos. Além disso, é preciso considerar eventuais condenações impostas em outras ações penais e, consequentemente, a unificação da pena (art. 111 da Lei 7.210/84).

Nesse cenário, o Juízo da Execução revela-se o órgão jurisdicional adequado para tanto apreciar o comportamento do apenado quanto para avaliar a situação prisional do acusado e também o cumprimento efetivo do lapso temporal previsto no art. 112 da Lei 7.210/84.

Acerca do tema:

Apelações - Roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, praticados em concurso formal (art. 70 do CP) - Condenação - Recursos dos corréus - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova oral harmônica e coesa - Vítimas que narraram com detalhes a empreitada criminosa e reconheceram os apelantes - Nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial relevância - Policiais militares que prenderam os recorrentes em flagrante, na posse dos objetos roubados e da arma de fogo - Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade - Apelantes que confessaram, em juízo, a prática delituosa - Condenação de rigor - Pedido de incidência de apenas uma das causas de aumento - Descabimento - É perfeitamente possível a cumulação de causas

de aumento previstas na Parte Especial do Código Penal, mediante fundamentação concreta, pois o art. 68, parágrafo único, do referido diploma legal consagra uma faculdade do julgador - Requerimento de aplicação da majorante do concurso de pessoas em seu patamar mínimo - Pedido recursal que carece de sentido, pois o d. Magistrado sentenciante assim já o fez - Pleito de afastamento do concurso formal de crimes - Impossibilidade - A conduta dos apelantes, no mesmo contexto fático, lesou patrimônios distintos - Requerimento de aplicação da detração prevista no art. 387, §2º, do CPP - Não acolhimento - Juízo das Execuções Penais ostenta melhores condições para analisar o instituto da detração, porquanto detém, com exatidão, todas as informações relativas à situação prisional do acusado - Pedido de fixação do regime inicial semiaberto - Inviabilidade - Regime inicial deve ser o fechado, em virtude do "quantum" de pena aplicado (superior a oito anos) e da reincidência dos apelantes - Requerimento de revogação da prisão preventiva do corréu C.S.N. - Inviabilidade - Subsistência do "periculum libertatis" (perigo da liberdade), consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública - Reincidência e gravidade concreta do delito evidenciam o risco de reiteração delitiva - Recursos não providos.

(TJSP; Apelação Criminal 1500138-97.2020.8.26.0548; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/07/2021; Data de Registro: 02/07/2021)

Roubo - Momento consumativo - Entendimento O entendimento jurisprudencial predominante, inclusive no Pretório Excelso, reputa consumir-se o roubo já no momento em que o agente se torna possuidor da res subtraída mediante grave ameaça ou violência, sendo irrelevante que a coisa tenha ou não saído da esfera de vigilância da vítima. Concurso de Crimes - Roubo simples - Ocorrência de mais de uma subtração contra vítimas diversas e patrimônios distintos em um único contexto - Reconhecimento do concurso formal e não de crime único Não se cogita da ocorrência de crime único - mesmo quando a ação é única - na hipótese de terem sido atingidos os patrimônios de vítimas diferentes, restando configurado o concurso formal, nos termos do art. 70 do CP. Pena - Roubo simples praticado mediante emprego de violência real contra mulher - Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena Em se tratando de roubo simples, a opção pelo regime semiaberto mostra-se, em regra, como suficiente, tanto em razão do quantum da pena fixada, como em função da natureza da conduta, que é normalmente indicativa da desnecessidade quanto a adoção de medidas mais rígidas de controle do processo de ressocialização do réu. Em se cuidando, todavia, de roubo praticado mediante emprego de violência real contra mulher, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, uma vez tratar-se de delito que, além de denotar maior ousadia e periculosidade por parte do agente, causa considerável abalo no corpo social, de modo a apresentar-se na atualidade como grande fonte de inquietação. Pena - Detração - Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade - Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 - Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP - Entendimento O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo

Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

(TJSP; Apelação Criminal 1501088-72.2019.8.26.0603; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021)

Inexiste dano a ser indenizado (art. 387, IV, do Código de Processo Penal). Ausentes às hipóteses dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, mantenho a liberdade provisória dos réus (art. 387, §1º, do Código de Processo Penal).

Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários em favor do(a)(s) advogado(a)(s) nomeado(a)(s) nos autos, nos termos do convênio DP/OAB.

Autorizo a destruição das drogas apreendidas (art. 72 da Lei 11.343/06).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado: (i) remetam-se os autos à contadoria para o cálculo das custas e da pena de multa e, após, proceda-se ao seu recolhimento na forma do art. 686 do Código de Processo Penal; (ii) oficie-se o TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; (iii) comunique-se a Corregedoria Geral de Justiça para fins estatísticos e para registros nos antecedentes criminais dos acusados.

Cachoeira Paulista, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA